

1529703-62.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... de agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Ademais, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/2018, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529703-62.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529703-62.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2334887/2021 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 21855822 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 5513/21/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2334887 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Wallace Eduardo da Silva e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

WALLACE EDUARDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, por duas vezes, cc o art. 69, ambos do Código Penal, porque no dia 08 de dezembro de 2021, em horário incerto, próximo à Rua Gurijuba, Jardim Romano, nesta cidade e Comarca, previamente ajustado e agindo em unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma bolsa, contendo diversos pertences da vítima Safira de Jesus Souza Penteado.

Consta, ainda, que, no dia 08 de dezembro de 2021, em horário incerto, na Rua Diogo Gonçalves Laço, Bairro Jardim Romano, nesta cidade e Comarca, WALLACE EDUARDO DA SILVA, previamente ajustado e agindo em unidade de desígnios, com indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho de telefonia celular, pertencente à vítima Ketthellen Brajl de Lima.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, o denunciado e seu comparsa decidiram praticar crimes patrimoniais.

Na ocasião, avistaram a vítima Safira, próxima à Rua Gurijuba, Jardim Romano, oportunidade em que se aproximaram em uma moto de cor vermelha, com uma mochila de entregador também vermelha e anunciaram o assalto. Na sequência, o piloto da motocicleta desembarcou, portando um revólver, e exigiu que a vítima entregasse sua bolsa, o que foi feito, tendo os roubadores tomado rumo ignorado.

Na mesma data, ainda a bordo da motocicleta de cor vermelha e com a mochila de entregador vermelha, WALLACE e seu comparsa não identificado abordaram a vítima Ketthellen, que voltava da escola pela Rua Diogo Gonçalves Laço, Jardim Romano, momento em que o indivíduo que estava garupa, portando um revólver, anunciou o assalto e exigiu o telefone celular da vítima, que foi imediatamente entregue. Ato contínuo, o denunciado e seu comparsa determinaram que a ofendida continuasse andando e fugiram do local.

Ocorre que, posteriormente, Policiais Militares foram acionados por um motorista do aplicativo Uber, que relatou ter visto dois indivíduos em uma moto vermelha, e com mochila vermelha, praticando roubos a transeuntes, na Rua Diogo da Costa Tavares.

Os Policiais, então, veicularam a informação via rádio.

Após buscas, Policiais Militares avistaram, na Rua Domingues Fernandes Nobre, altura do nº 151, dois indivíduos, com arma de fogo em punho, em motocicleta com as características descritas, realizando roubo a uma vítima transeunte. Ao notarem a aproximação policial, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga.

Durante acompanhamento, na Rua Armando de Nóbrega, o ora denunciado, que estava na garupa da motocicleta, ainda com arma em punho, se virou em direção à viatura que estava em acompanhamento logo atrás, para efetuar disparos contra os policiais, momento em que o 3º Sgt PM Paulo Henrique Ribeiro, diante do risco, e para repelir a injusta agressão iminente, efetuou cinco disparos de arma de fogo, tendo um dos projéteis atingido as costas do denunciado, na altura do ombro.

O denunciado e seu comparsa, então, perderam o controle da motocicleta e caíram ao solo, tendo o indivíduo não identificado logrado êxito em evadir do local. Já o denunciado, lesionado, foi detido pelos policiais e identificado como WALLACE EDUARDO DA SILVA, sendo socorrido pelo SAMU, ao Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista.

Antes de cair ao solo, WALLACE dispensou a arma de fogo, que foi localizada e apreendida pelos policiais (revólver cal. 32 com 06 munições percutidas, ou seja, com disparo sem sucesso - cf. auto de exibição e apreensão de fls. 33). Enquanto aguardavam socorro, o denunciado admitiu informalmente aos policiais que ele e o comparsa de prenome Eliseu estavam praticando roubos.

Na ocasião, em poder do denunciado, foi localizado o telefone celular da vítima Ketthellen, a bolsa com pertences da vítima Safira e um Tablet de propriedade não identificada.

Em diligências, foram identificaram duas vítimas dos roubos - Ketthellen e Safira - sendo que ambas reconheceram pessoalmente o denunciado como um dos autores dos delitos que que sofreram (fls. 14 e 15).

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada sua prisão preventiva, após audiência de custódia, em decisão de fls. 61/64.

A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2022 (fls. 92/94).

O acusado foi citado (fls. 131), foi apresentada resposta à acusação (fls. 135/136) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 137).

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima, testemunhas comuns e, após, foi o réu interrogado.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a procedência total da ação para condenar do réu nos exatos termos da denúncia.

O Defensor Público, por seu turno, requereu a absolvição do acusado, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, pena no mínimo legal, compensação da confissão com a reincidência, um só aumento na segunda fase com base no art. 68 do Código Penal e reconhecimento de crime continuado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e autoria do delito surgem da prova oral coligida aos autos, do Boletim de Ocorrência de fls. 02/07, dos autos de reconhecimento pessoal de fls. 14/15, do auto de exibição e apreensão de fls. 32/33 e do laudo pericial de fls. 109/121, que apontou resultado positivo para "vestígios produzidos por disparo recente".

Assim, o acusado foi preso em flagrante, em poder dos bens de ambas as vítimas. Tal situação, como vêm entendendo nossos Tribunais, inverte o ônus da prova, devendo o réu provar a licitude de tal posse, no que não lograram êxito os acusados no presente feito. Cito:

"PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório: No crime de roubo, a apreensão da res em poder do acusado faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus probatório." (TACrimSP - Ap. nº 1.410.455/6 - São José do Rio Preto - 7ª Câmara - Rel. Salvador D'Andréa - J. 15.1.2004 - v.u).

"PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente a respeito da posse - Inversão do ônus probatório - Ocorrência: No crime de roubo, a posse da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente, inverte o ônus da prova, que se torna de sua exclusiva responsabilidade." (TACrimSP - Ap. nº 1.307.177/4 - São Paulo - 14ª Câmara - Rel. Oldemar Azevedo - J. 21.5.2002 - v.u).

Em Juízo, o acusado CONFESSOU a prática do delito. Estava com outro rapaz e arma de fogo, em uma motocicleta. Abordaram uma moça e subtraíram a bolsa dela. Depois de dois quarteirões, roubaram um celular de outra moça. Quando estavam fugindo, não viram a viatura, escutou barulho de pneu queimado, o piloto acelerou a motocicleta, os policiais atiraram, foi alvejado. Caíram no chão, foi detido pelos policiais, ele correu. As coisas das vítimas estavam na mochila de pizza. Estava precisando de dinheiro e ele lhe chamou, porque tinha a arma.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...)"(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima Safira de Jesus Souza Penteado, ouvida apenas na Delegacia de Polícia (fls. 12) narrou o roubo com arma de fogo e pluralidade de agentes.

A vítima Ketthellen Brajlil de Lima RECONHECEU o acusado em Juízo como autor do delito, pelas tatuagens em seus braços. Estava voltando da escola, por volta de 23h, cortou caminho, quando chegou na rua de sua casa, foi abordada pelo acusado e mais um com arma de fogo, exigindo seu celular, entregou o aparelho. Estavam com mochila de entregador de "Ifood". Foram embora com a motocicleta. Só o acusado tinha arma de fogo, ele era o garupa. Recuperou o aparelho. Teve uma crise de bronquite, foi para casa. Os policiais detiveram a pessoa, ligaram para sua irmã do chip de seu celular. Então foi para a Delegacia de Polícia reconheceu com certeza o acusado, ele estava com mechas loiras, viu a tatuagem, fitas que ele tinha no braço quando apontou a arma de fogo.

Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

“PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido.” (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

“PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido.” (TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u). Voto nº 7.553 - grifei

“PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido.”

(TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas.

O Policial Militar Bruno Felipe Ferraz dos Santos, reconhecendo o acusado em audiência, disse que estavam indo a uma viatura no posto de estacionamento. Eles informaram sobre roubos sendo efetuados por duas pessoas com caixa de Ifood vermelha. Encontraram a motocicleta, iniciaram uma perseguição, perderam o visual, eles estavam tentando roubar uma vítima com a arma na cabeça do ofendido. WALLACE virou para trás com a arma em punho, o sargento efetuou cinco disparos, eles caíram da motocicleta, o outro fugiu, conseguiram deter o acusado. Depois dos disparos, ele jogou a arma no chão, as munições estavam picotadas, era uma Taurus calibre 32. As vítimas o reconheceram. O acusado estava com a arma e os pertences dos ofendidos, um celular Samsung de Ketthellen e a bolsa da vítima Safira.

Suas palavras foram ratificadas pelo seu colega de farda, o Policial Militar Paulo Henrique Ribeiro, que também reconheceu o acusado e disse que atirou contra o acusado quando ele virou a arma para a viatura na fuga. As vítimas o reconheceram na Delegacia de Polícia. Ele estava com o celular de uma vítima e uma bolsa de outra e também um tablet, que não se descobriu o dono.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais milita a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

“RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL - Não se vislumbra nulidade decorrente da abreviação de atos processuais, sendo regular a mera ratificação, em juízo, das declarações prestadas

perante a autoridade policial - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA - SUFICIÊNCIA - As declarações das testemunhas de acusação, alicerçadas pela circunstância de a ré possuir folha de antecedentes desabonadora, demonstram, sem reboços, a prática do delito tipificado no artigo 304 do Código Penal - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PROVAS - SUFICIÊNCIA - Apreensão de instrumentos destinados à contrafação de talonários de cheques na residência da ré. - Alegação de que desconhecia o conteúdo da caixa destituída de embasamento - CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

O roubo restou, assim, consumado, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

E a jurisprudência:

"Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se consumado o delito de roubo "no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima" (HC 118.407/ SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09). 2. Ordem denegada" (HC 155108/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima DJ 03.05.2010).

"O crime de roubo está consumado se o agente, ainda que por breve momento, tem, após o desapossamento violento, a disponibilidade dos objetos. Não é exigível a posse tranquila da res furtiva, bastando que cesse a violência ou a clandestinidade" (STJ/EResp/DF 197848, Min Edson Vidigal, DJ 15.05.2000).

Ademais, de rigor o reconhecimento das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma, tanto pela prova oral coligida aos autos quanto pelo laudo pericial da arma de fogo de fls. 109/121.

Deixo de adotar o postulado pelo douto Dr. Defensor Público, de aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, por entender que se trata de uma discricionariedade do julgador - "art. 68 (...) Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua" (grifei) - e não se pode equivaler as situações de ser

roubado por mais de uma pessoa com a de ser roubado com superioridade numérica e também uso de arma de fogo. Tanto é uma situação mais grave esta última que o legislador, com o advento da Lei nº 13.654/18, ao inserir o §2º-A ao art. 157 do Código Penal, quis garantir o aumento em 2/3 da pena daquele que emprega arma de fogo em um roubo, bem como do que emprega explosivo ou análogo, pela periculosidade de tais condutas, independentemente das outras causas de aumento do §2º do mesmo dispositivo legal. Desta forma, respeitando a vontade do legislador, bem como a individualização das penas, entendendo que não se pode equalizar situações desiguais, ainda mais em delitos violentos, entendo que devem ser aplicadas as duas causas de aumento de pena previstas no art. 157, tal como constantes da denúncia. De mais a mais, acabar-se-ia por atenuar fortemente o louvável intuito do legislador que, ao editar a Lei 13.654/18, atendendo a reclamos da maior parte da população brasileira, logicamente lograva punir com maior severidade o roubador aparelhado com armas de fogo que, todos os dias, tantas mortes de cidadãos de bem causam no curso de assaltos do estilo. No sentido da possibilidade da cumulação: STJ - HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018.

No caso em tela, o acusado estava com outro roubador, com a arma de fogo inclusive apreendida e apontou a arma de fogo para as vítimas e tentou dispará-la contra os policiais. Enfim, justificado o emprego das duas majorantes.

Neste sentido é o entendimento da Colenda 8ª Câmara do E. TJSP:

“APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das penas, com afastamento da causa de aumento de emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida. Bem delineada a incidência da aludida causa de aumento, prescindível, para tanto, a apreensão ou perícia do artefato, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores - Acusação requer a elevação da reprimenda, aplicando-se cumulativamente o aumento decorrente do reconhecimento do concurso de agentes e aquele relativo ao emprego de arma de fogo - Cabimento Suficientemente demonstrada a incidência de ambas as majorantes, as quais se mostraram igualmente determinantes na concretização do delito, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, é o caso de adequar-se as penas impostas, nos moldes pretendidos pela Acusação Apelo defensivo não provido e apelo ministerial provido. (...) Na terceira etapa, razão assiste ao i. representante do órgão ministerial quando refere que o cálculo da pena fixada comporta reparo. Explico. Ocorre que diante do reconhecimento das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e §2º - A, inciso I, do Código Penal, entendeu o d. magistrado “a quo” pela aplicação apenas daquela prevista no §2º - A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, no importe de 2/3 (dois terços), com base no artigo 68, parágrafo único, do mesmo Códex. Data vênha, entendo que tal interpretação veio a beneficiar indevidamente o acusado, mormente porque não se pode simplesmente igualar a ação daquele que age unicamente valendo-se de arma de fogo, com a daquele que, por exemplo, o faz também em concurso de agentes, o que via de regra reduz ainda mais a possibilidade de resistência da vítima e implica em maior possibilidade de sucesso na empreitada criminosa. É necessário, a meu ver, analisar casos desta natureza com especial acuidade, visando resguardar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Não se pode olvidar que mesmo antes da alteração trazida pela Lei n.º 13.654/2018, permitia-se a cumulação da causa de aumento de emprego de arma de fogo com quaisquer das demais majorantes legalmente previstas no §2º do art. 157 do Código Penal, sendo aplicadas frações variáveis e proporcionais à quantidade daquelas, de acordo com seu reflexo no caso concreto, evidentemente. E o que pretendeu a nova lei, como é cediço, foi conferir às ações criminosas praticadas mediante utilização de arma de fogo, tratamento mais enérgico, compatível com a gravidade peculiar advinda de tal circunstância, sendo, pois, um contrassenso, que se ignorasse, agora, a existência concomitante de causas de aumento outras, que permanecem legalmente previstas e dispostas no parágrafo anterior. Nesse sentido, vem decidindo esta Colenda Câmara: “APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Sentença condenatória pelo art. 157, §2º,

inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Recurso Defensivo buscando o afastamento das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma (§2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal). Alegação de inconstitucionalidade material da fração de aumento do art. 157, § 2º-A, do Código Penal, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, e impossibilidade de cumulação entre as referidas causas de aumento. Pedidos subsidiários de fixação de regime semiaberto e detração da pena. Autoria e materialidade comprovadas Prisão em flagrante Réu que confessou parcialmente a prática delitiva, negando, apenas, o emprego de arma de fogo Vítima que confirmou que o réu praticou o delito de roubo em questão, com a participação de um comparsa e o emprego de armas de fogo, tendo sido ameaçada durante a empreitada criminosa. Réu e comparsa que subtraíram o veículo da vítima e se evadiram, tendo sido encontrados pela Polícia algumas horas depois, na posse do veículo subtraído Acusado que conduzia o carro roubado, e o colidiu durante a perseguição policial Reconhecimento pessoal positivo Palavra da vítima que merece credibilidade Roubo consumado Delito que se consumou com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima Crime cometido com violência e grave ameaça. Causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma sobejamente demonstradas pela prova colhida desnecessidade de apreensão da arma de fogo para a configuração da majorante, quando devidamente calcada em outros elementos de prova. Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes Na terceira fase, causas de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, e do § 2º-A, inciso I, que são perfeitamente cumuláveis, à luz do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal a eventual não cumulação de causas de aumento ou de diminuição é faculdade do Julgador, conforme expressamente previsto em lei alegada inconstitucionalidade material da fração de aumento trazida pela Lei nº 13.654/18 que não merece prosperar Legislador que previu fração de exasperação mais gravosa para conduta de lesividade mais elevada (emprego de arma de fogo), não havendo qualquer afronta ao princípio da proporcionalidade manutenção das exasperações de pena pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, cumulativamente. (...) Recurso da Defesa desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 0048158-09.2018.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 24/05/2019 grifos nossos). Com efeito, ao prever que 'no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição (...)', o parágrafo único do art. 68 do Código Penal estende ao julgador uma faculdade (e não um dever). Nessa toada, tem-se o entendimento das Cortes Superiores, bem destacado pela d. Procuradoria Geral em seu parecer: "(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta (...)". (STJ, HC nº 472771/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 13/12/2018). Também nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação Criminal nº 1501213-85.2018.8.26.0567 -Voto nº 39.442 19 CORPUS: CF, ART. 102, I, "D" E "I". ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, "A") E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). (...) IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICOTEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. [...] 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de

ser padrasto da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. [...] 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual. (HC 110.960/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/09/2014). E, no caso em apreço, é de ser dito que ambas as majorantes devem ser aplicadas. Sucede que, por um lado, conforme apontou a d. Procuradoria Geral, em consonância com o mencionado entendimento das Cortes Superiores, “não foi apresentada justificativa concreta para a opção pelo aumento único. A bem ver, houve mera invocação abstrata do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, sem que se cogitasse da proporcionalidade da punição em relação aos fatos” (fls. 213). Por outro lado, observa-se que a presença de ambas as majorantes reconhecidas em desfavor do acusado foram de fato determinantes para a rendição do ofendido e consumação da ação criminosa. No caso, não bastasse o delito ter sido perpetrado mediante uso de arma de fogo, os roubadores ainda se valeram da superioridade numérica (pelo menos dois agentes) para ameaçar a vítima, que teve o dinheiro do caixa do estabelecimento subtraído e, também, o veículo de sua propriedade, que se encontrava estacionado em frente ao local. Evidente que um único agente, ainda que munido de arma de fogo, teria encontrado maior dificuldade ou quicá resistência por parte do ofendido para efetuar tal ação, já que haveria de manter sozinho a vítima subjugada enquanto buscasse, após subtrair-lhe

o dinheiro do caixa, adentrar ao veículo que estava estacionado junto à via pública e sair rapidamente na condução dele. Tais fatores, portanto, se mostram hábeis a justificar, com base no caso específico dos autos (exatamente conforme orienta a jurisprudência das Cortes Superiores), a necessidade de aplicação cumulativa das duas causas de aumento reconhecidas pela r. sentença condenatória, como requer o “Parquet”. (TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal nº 1501213-85.2018.8.26.0567 – Relator Desembargador SÉRGIO RIBAS – j. 5/12/2019 - grifei).

Inafastável, assim, a condenação do acusado por infração ao art. 157, §2º, II e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, pois não configurado o concurso material de delitos. Pelo que consta, os dois roubos foram praticados sequencialmente.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O réu é reincidente específico, e responde a outro processo criminal (fls. 56/57 e 83/86).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base de cada um dos delitos no mínimo legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo.

Compenso a confissão com a reincidência.

Pela causa de aumento do concurso de agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Ademais, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/2018, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.

No caso, ademais, rigor o reconhecimento do crime continuado, na medida em que os roubos se deram na sequência um do outro, em tempo e local, pelo que, nos termos do art. 71 do Código Penal, pelo que aplico a pena do delito majorado e aumento em 1/6, totalizando dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão e pagamento de 24 dias-multa.

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu WALLACE EDUARDO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 24 dias multa, com unidade no mínimo legal.

Vez que reincidente específico e condenado por delito grave e violento, o réu não faz jus a qualquer benefício.

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de suas penas em regime fechado, pela pena aplicada, pela sua reincidência específica pela gravidade de sua conduta, bem como por sua personalidade deturpada e voltada à prática delitiva, não merecendo o roubador qualquer tratamento indulgente.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

“Cabe ao magistrado estabelecer o regime de cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo terceiro, do CPB, sopesando os critérios previstos no artigo 59 do supracitado dispositivo legal. Desfavoráveis estes, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, cabível a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena” (TJDF - Ap. Crim. nº 18.051/97 - 2ª T. - Rel. Desa. Aparecida Fernandes - J. 29.10.97-DJ.18.02.98).

Anote-se também o precedente do C. STJ:

“A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal” (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, a sua reincidência e reiteração criminosa, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; intime-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa imposta (se o caso); e oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.R. C.

São Paulo, 17 de maio de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA